

1500488-67.2021.8.26.0187

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARIO HENRIQUE GEBRAN SCHIRMER

Comarca: Fartura

Foro: Foro de Fartura

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 12/01/2022

... foi presa em flagrante delito por tráfico ilícito de substâncias entorpecentes em outros autos, sendo apreendido o celular desta, em que se constatarem conversas típicas de tráfico de drogas entre ela e o denunciado TALISON THIAGO DA CUNHA (fls. 86/96) Em razão disso, a autoridade policial representou pela expedição de mandado de busca e apreensão na residência do denunciado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Fartura

Foro de Fartura

Vara Única

Rua Anacleto Gonçalves Neves, 250, Fartura-SP - cep 18870-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500488-67.2021.8.26.0187 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500488-67.2021.8.26.0187

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2218852/2021 - DEL.POL.FARTURA, 19586837 - DEL.POL.FARTURA, 400/21/120 - DEL.POL.FARTURA, 2218852 - DEL.POL.FARTURA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TALISON THIAGO DA CUNHA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIO HENRIQUE GEBRAN SCHIRMER

Vistos.

Trata-se de AÇÃO PENAL proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em desfavor de TALISON THIAGO DA CUNHA e BRUNA ALESSANDRA DOS SANTOS, ambos já qualificado nos autos, pela suposta prática do delito previsto art. 35, da Lei 11.343/06, e, especificamente para Talison, também, a suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, por duas vezes, e art. 12, da Lei 10.826/03.

A denúncia foi deduzida nos seguintes termos:

“(Fato 01) Consta do incluso Inquérito Policial que, em data e local não conhecido, mas antes do dia 21 de junho de 2021, BRUNA ALESSANDRA DOS SANTOS, qualificada nos autos nº 1500162-13.2021.8.26.0574, e TALISON THIAGO DA CUNHA, qualificado em fl. 5, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente, o crime

de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. (Fato 02) Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 28 de julho de 2021, em horário e local ignorados, nesta cidade e Comarca de Fartura, TALISON THIAGO DA CUNHA vendeu 50 g (cinquenta gramas) da substância entorpecente do tipo maconha, ao usuário Lucas Antunes Domingues, conforme mensagens realizadas pelo Facebook às fls. 20/23, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (Fato 03) Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 12 de agosto de 2021, por volta das 12h50min, na residência situada na Rua José Cardoso de Lima, 86 fundos, Vila Esperança, nesta cidade e Comarca de Fartura, TALISON THIAGO DA CUNHA tinha em depósito 01 (uma) porção de maconha, pesando aproximadamente 14 g (catorze gramas), conforme boletim de ocorrência de fls. 6/10, auto de exibição e apreensão de fl. 11, auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fl. 12 e laudo de exame toxicológico de fls. 138/140, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (Fato 04) Consta do incluso Inquérito Policial que, nas mesmas circunstâncias de data, horário e local do fato anterior, TALISON THIAGO DA CUNHA no interior de sua residência, mantinha sob sua guarda arma de fogo de uso permitido, do tipo revólver, marca Taurus, Calibre 38, número 683608, acompanhada de 8 (oito) munições, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo apurado, os denunciados BRUNA ALESSANDRA DOS SANTOS e TALISON THIAGO DA CUNHA estavam associados para a prática do crime de tráfico de drogas, sendo que este adquiria drogas daquela para revender, conforme mensagens de WhatsApp de fls. 95/96. [PRINTS DE TELA]. Na referida conversa, há uma mensagem de áudio, que conforme o relatório de investigações de fls. 88/90, consta a seguinte mensagem: [CÓPIA DE MENSAGEM]. As drogas adquiridas, o denunciado TALISON THIAGO DA CUNHA eram vendidas para diversas pessoas, tais como Ademir Prado Felizardo e Lucas Antunes Domingues. Pela conversa pelo aplicativo WhatsApp entre o denunciado TALISON THIAGO DA CUNHA e Ademir Prado Felizardo, aquele faz cobranças por dívida de tráfico: [PRINTS DE TELA]. Além disso, pela conversa pelo aplicativo Facebook entre o denunciado TALISON THIAGO DA CUNHA e Lucas Antunes Domingues, há uma negociação para este adquirir 50 gramas de maconha, que seriam adimplidas àquele somente na data do pagamento: [PRINTS DE TELA]. É cerro que, no dia 12 de agosto de 2021, o denunciado possuía, em cima do caibro da garagem da residência, no interior de uma caixinha, uma porção de maconha, destinada ao comércio ilegal de drogas. Ademais, atrás do sofá, havia uma arma de fogo da marca Taurus, calibre 38, que estava municiada com 7 (sete) cartuchos íntegros e 01 (um) deflagrado. O fato foi descoberto porque a denunciada BRUNA ALESSANDRA DOS SANTOS foi presa em flagrante delito por tráfico ilícito de substâncias entorpecentes em outros autos, sendo apreendido o celular desta, em que se constatarem conversas típicas de tráfico de drogas entre ela e o denunciado TALISON THIAGO DA CUNHA (fls. 86/96) Em razão disso, a autoridade policial representou pela expedição de mandado de busca e apreensão na residência do denunciado TALISON THIAGO DA CUNHA, que foi deferido pelo presente Juízo, nos autos nº 1500473-98.2021.8.26.0187, autorizando o acesso aos dados de celulares (fls. 40/41). O mandado de busca e apreensão foi cumprido pelos policiais civis Paulo César de Souza, Ari Sebastião da Silva e Marco Adriano Valente, que apreenderam uma porção de maconha, uma arma de fogo e o aparelho de telefone celular (fls. 127/129). Dentre outras mensagens que constatarem no aparelho de telefone celular dele, verificaram que o denunciado TALISON THIAGO DA CUNHA cobrou Ademir Prado Felizardo sobre uma dívida de drogas, além de uma negociação de entrega de 50 gramas de substância entorpecente ao senhor Lucas Antunes Domingues (fls. 131/132). Pelas circunstâncias dos fatos, conversas por redes sociais com conteúdo relacionado ao tráfico de drogas, apreensão de maconha e arma de fogo na residência de TALISON THIAGO DA CUNHA, todos esses fatos em conjunto comprovam a prática da traficância, seu dolo e que os denunciados TALISON THIAGO DA CUNHA e BRUNA ALESSANDRA DOS SANTOS estavam associados para tal fim" (fls. 155-163).

A prisão em flagrante do acusado Talison foi convertida em preventiva (fls. 68-72). Os acusados apresentaram defesa prévia (fls. 293-303; 321-328). A denúncia foi recebida 18 de outubro de 2021 (fls. 330-333), sendo rejeitada e

possibilidade de absolvição sumária e designada audiência de instrução, debates e julgamentos.

Foi produzida a prova oral, com a oitiva das testemunhas, bem como a inquirição dos acusados, por meio de sistema de gravação audiovisual, em audiência realizada por videoconferência, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020 (fls. 401-403; 437 e mídias anexas).

Encerrada a fase de instrução, o i. representante do Ministério Público, em sede de alegações finais (fls. 444-456), pleiteou, em síntese, pela condenação dos acusados, sustentando a comprovação dos fatos nos exatos termos em que narrados na denúncia e pedindo a fixação de regime inicial fechado a ambos os acusados.

A defesa dos acusados apresentou alegações finais (fls. 457-466), argumentando, em síntese, que: (i) não demonstrado o tipo penal do art. 35, da Lei 11.343/06, uma vez que não demonstrada a associação entre os acusados; (ii) ausente a comprovação de que os acusados praticavam o tráfico de drogas, sendo, portanto, indevida a condenação pelo art. 33, da Lei de Drogas; (iii) subsidiariamente, com relação à imputação do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, a conduta deve ser desclassificada para o tipo previsto no art. 28, da Lei 11.343/06 ou, ainda de maneira subsidiariamente, a aplicação do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, com a redução da pena em patamar máximo e a fixação de regime aberto; (v)

subsidiariamente, em caso de condenação, postulou pela fixação de regime aberto e pugnou pela possibilidade de aplicação do art. 44, do CP.

Foi concedida liberdade provisória ao acusado (fls. 467-469).

O feito veio concluso para julgamento.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

1. Inexistem alegações a respeito do trâmite processual e, tampouco, há, neste contexto, matéria a se conhecer de ofício, dado que o feito transcorreu regularmente.

Por esta razão, é possível o julgamento do mérito da pretensão punitiva.

2. Antes, todavia, são necessários alguns apontamentos a respeito do standard probatório reclamado para a legitimação de uma condenação na seara penal. Afinal, a imposição de quaisquer penalidades pressupõe, para sua validade, não apenas o efetivo exercício de coerção, antes exigindo, também, que o poder estatal esteja assentado em premissas discursivas de legitimação (a respeito ver: FORST, Rainer. Justificação e Crítica – perspectivas de uma teoria crítica da política. São Paulo: Editora Unesp, 2018; ARENDT, Hannah. Sobre a Violência. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009). Trata-se, ao fim e ao cabo, da necessidade de justificação do poder, o que é inerente ao próprio conceito de democracia.

Nesse contexto, a imposição de penas exige que o decreto condenatório esteja alicerçado em provas e fundamentos que conduzam a uma conclusão que se coloca além de um patamar de 'dúvida razoável' a respeito da existência e autoria delitivas. Neste sentido é a doutrina de Gustavo Badaró, ao afirmar que, conquanto a atividade probatória ambicione a reconstrução de fatos históricos – os quais, por evidente, não podem ser reproduzidos de maneira idêntica e absoluta –, nas hipóteses de procedência da pretensão punitiva deverá ser alcançada uma conclusão assentada em um "altíssimo grau de probabilidade" de ocorrência dos fatos tais como narrados na denúncia (BADARÓ, Gustavo. Ônus da prova no processo penal. São Paulo: Editora RT, 2003, p. 62). Isto se traduz, em síntese, em afirmar que a possibilidade de condenação está à mercê da maior ou menor solidez do contexto probatório que se está inserido, sendo, no entanto, necessário, sempre, um mínimo de lastro probatório para que se possa proferir um decreto condenatório.

Diante disso, não se pode olvidar que, de maneira geral, a legislação e a jurisprudência pátrias pouco se ocuparam do estabelecimento de qual seria este 'nível probatório mínimo' exigível para um decreto condenatório, quase sempre se restringindo somente a lançar mão dos conceitos de 'persuasão racional' e 'livre convencimento do juiz'.

Em contrapartida, a experiência estrangeira tem evidenciado a importância da fixação de um parâmetro da existência de prova "acima de uma dúvida razoável" (proof beyond a reasonable doubt).<https://www.google.com.br/search?>

q=Federal+Judicial+Center,+Pattern+Criminal+Jury+Instructions.&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=psCBVaPWbCy5ggT6mK-ADQ Portanto, se é verdade que a natureza temporal das provas – enquanto pretensão da reconstrução histórica de fatos – importa no reconhecimento da inexistência de verdades ou provas absolutas, é igualmente verdade que a exigência de um standard de "prova acima de uma dúvida razoável" se traduz em mecanismo que impede a livre valorização dos fatos a bel-prazer arbitrário de cada julgador.

Ainda assim, nas excepcionais oportunidades em que a temática foi analisada pelas Cortes pátrias, foi destacada a imprescindibilidade de que o standard probatório esteja em patamar 'acima de dúvida razoável'. Nesse sentido, o e. Supremo Tribunal Federal já afirmou a importância de demonstrar a ocorrência de fatos 'para além de dúvida razoável':

"DIREITO PENAL. AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. OPERAÇÃO SANGUESSUGA. FRAUDE EM LICITAÇÃO. CRIME DO ART. 90 DA LEI 8.666/1993. CORRUPÇÃO PASSIVA. QUADRILHA. DEPUTADO FEDERAL. FALTA DE PROVA HÁBIL. ABSOLVIÇÃO. 1. A presunção de inocência, princípio cardeal no processo criminal, é tanto uma regra de prova como um escudo contra a punição prematura. Como regra de prova, a melhor formulação é o "standard" anglo-saxônico - a responsabilidade criminal há de ser provada acima de qualquer dúvida razoável -, consagrado no art. 66, item 3, do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. 2. A falta de prova suficiente da participação do acusado, Deputado Federal, nos crimes licitatórios praticados com verbas decorrentes de emendas parlamentares de sua autoria, bem como do recebimento de vantagem indevida em decorrência das emendas parlamentares e, ainda, de associação a grupo dedicado à prática de fraudes e peculatos na aquisição de ambulâncias com recursos federais, impõe-se a absolvição. 3. Ação penal julgada improcedente." (AP 521, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, publicado em 06-02-2015 - destaquei)

"Queixa-crime ajuizada contra parlamentar. Injúria. Delito praticado por meio de matéria divulgada em periódico escrito. Alegada falta de justa causa por inexistência de dolo específico voltado a atingir a honra da vítima. Necessidade da dilação probatória. Subsunção dos fatos à conduta típica descrita na inicial acusatória. Queixa recebida. 1. A verificação acerca da narração de fato típico, antijurídico e culpável, da inexistência de causa de extinção da punibilidade e da presença das condições exigidas pela lei para o exercício da ação penal (aí incluída a justa causa) revela-se fundamental para o juízo de admissibilidade de deflagração da ação penal. A inexistência de dolo específico é questão que deve situar-se no âmbito da instrução probatória, por não comportar segura ou precisa análise nesta fase processual, que é de formulação de um simples juízo de delibação. 2. As condutas em foco, todavia, se amoldam, em tese, ao delito invocado na peça acusatória, sendo que a defesa apresentada pelo querelado não permite concluir, de modo robusto, ou para além de toda dúvida razoável, pela improcedência da acusação. 3. Queixa recebida." (Inq 2968, Relator Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, publicado em 17-08-2011 - destaquei).

O Superior Tribunal de Justiça já adotou idêntico posicionamento:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 2º DA LEI N. 8.176/1991 E ART. 55 DA LEI N. 9.605/1998. CONCURSO FORMAL. PRESCRIÇÃO. FALTA DE PROVAS. (...) 5. O estado jurídico de inocência, corolário da dignidade da pessoa humana, exige para a condenação a certeza além da dúvida razoável, não sendo admissível sequer a alta probabilidade. Ausentes elementos de prova aptos a demonstrar os fatos imputados, devem os réus ser absolvidos com fundamento no art. 386, II, do CPP. Ação penal julgada improcedente, absolvendo-se os acusados com fundamento no art. 386, II, do CPP". (APn 719/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 18/11/2014 - destaquei).

Feitas tais considerações gerais a respeito dos níveis probatórios necessários a comportar um decreto condenatório, passo ao exame dos elementos de prova existentes nos autos para atestar a comprovação, ou não, da prática do delito imputado ao réu. 3. Analisando-se os elementos de informação, bem como a produção de provas em juízo, verifico que a materialidade dos delitos ficou comprovada – com exceção a imputação do fato 01 da denúncia, conforme exposto no tópico 5 – por intermédio do

Auto de Exibição e Apreensão (fl. 11), Auto de Constatação de Substância (fl. 12), fotos (fls. 13-27), Auto Circunstanciado de Busca (fl. 127-129), Relatório Final das Investigações (fls. 148-150), Auto de Exibição e Apreensão (fl. 177), Laudo Pericial na arma de fogo e munições (fls. 210-218), laudo pericial das conversas telefônicas (fls. 87-118; 417-431), Laudo pericial toxicológico (fls. 138-140)

4. A autoria está também demonstrada, pesando em desfavor do acusado Talison, sobretudo pelos depoimentos apresentados em juízo, bem como pelo laudo pericial das conversas telefônicas (fls. 417-431).

Nesse contexto, a testemunha Paulo César (investigador de polícia) narrou, em síntese, que em junho cumpriram um mandado de busca e apreensão no endereço de Bruna, sendo ela presa em flagrante. Disse que em seu celular foram encontradas mensagens – haja vista que deferida a quebra do sigilo telefônico – entre a acusada Bruna e o acusado Talison a respeito da compra e venda de entorpecentes. Em razão das informações, realizaram campanhas em frente a casa do acusado Talison, tendo constada a circulação de muitas pessoas, o que evidenciava a venda de drogas. Diante das informações coletadas, foi solicitado e deferido mandado de busca e apreensão na residência do acusado Talison, local em que foram apreendidas uma porção de drogas, um revólver calibre 38, munições e um telefone celular, em que existiam conversas que evidenciam a venda de drogas pelo acusado.

A testemunha Marcos (investigador de polícia) disse ter participado do cumprimento do mandado de busca e apreensão, na residência do acusado Talison, sendo que no local encontraram uma porção de maconha, um revólver calibre 38 – que estava escondido debaixo do sofá da casa – e um celular, no qual existiam mensagens que evidenciavam a prática de traficância pelo acusado. Especificou que participou também de diligência pretéritas, em campanhas de frente a casa do acusado Talison, em que foi constatado o fluxo de pessoas conhecidos como usuários de drogas. Relatou, ainda, que ficou sabendo de informações implicando o acusado Talison como traficante por meio de mensagens que estavam no celular de Bruna, em que se evidenciavam as relações entre os acusados.

A testemunha Lucas Antunes Domingues, narrou, em síntese, que já manteve conversas com o acusado Talison a respeito da compra de maconha, tendo comprado, do acusado, 50g (cinquenta gramas) de maconha, por R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

A testemunha Lucas Willian Benatto disse ter enviado mensagem ao acusado, pelo aplicativo Messenger, para comprar maconha. Afirmou que sabia que o acusado era usuário de maconha e sabia que Talison, por vezes, 'passava' maconha para outras pessoas – tendo o depoente, inclusive, por vezes informado outras pessoas que Talison poderia 'passar' maconha. Relatou, especificamente, que já comprou maconha do acusado, por, mais ou menos, 04 ou 05 vezes, comprando cerca de R\$ 10,00 (dez reais) por vez.

O informante Ademir (amigo íntimo do acusado Talison) disse, em síntese, que já manteve diálogos com Talison sobre a compra de maconha. Afirmou ser usuário de maconha e que comprava droga de Talison, ficando devendo ao acusado em uma oportunidade, o que deu ensejo ao envio de mensagens de texto a respeito. Disse, ainda que comprava drogas com o acusado há, aproximadamente, 06 (seis) meses, em média uma vez ao mês, variando o valor comprado entre R\$ 10,00 (dez reais) a R\$ 50,00 (cinquenta reais).

A informante Valquíria (amiga íntima do acusado Talison) apresentou um relato abonatório. Disse ser colega de trabalho do acusado, há 04 (quatro) anos, mas nunca soube que o acusado seria traficante.

Em seu interrogatório, a acusada Bruna relatou, em síntese, que realmente vendia drogas, mas nunca se associou com o acusado Talison para a venda de drogas, pois realizava atividade delitiva sozinha. Especificamente, confirmou que já vendeu drogas ao acusado Talison, mas jamais se associou com ele, pois, em seu conhecimento, Talison era somente usuário de maconha. Disse que somente vendeu drogas para Talison por duas vezes, não lembrando exatamente a quantidade vendida. Relatou que o contato entre os acusados foi somente por mensagens e uma única vez. Disse que nunca soube que Talison vendia drogas.

Em seu interrogatório, o acusado Talison disse, em síntese, comprava drogas para consumo próprio, mas, eventualmente, revendia para amigos e conhecidos. Relatou que

recebeu a arma e mais dinheiro, em troca de uma moto, a qual teve que vender em razão de sua situação econômica. Disse que comprava drogas somente da acusada Bruna, sendo que adquiria maconha e, uma vez, também, cocaína. Negou que tivesse enviado mensagem à acusada.

5. Diante deste contexto, autoria e materialidade estão, de maneira geral, comprovadas, conforme passo expor adiante.

5.1. No ponto, ressaltado, em primeiro lugar, que os policiais narraram com clareza e de forma detalhada como se deram os fatos. Além disso, não há nos autos indícios de que eles tenham se manifestado de maneira maliciosa e temerária, imputando falsamente à prática criminosa a acusada. Ao contrário, o que se observa é que os agentes públicos asseveraram com precisão o desdobramento do fato, imprimindo certeza e seriedade em suas narrativas. Neste contexto, a jurisprudência, há muito, já firmou entendimento de que o testemunho dos policiais tem valor idêntico aos de outras pessoas que não possuam qualquer interesse no julgamento. Por todos, veja-se o posicionamento do e. Supremo Tribunal Federal:

"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência." (HC 73518, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26/03/1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293).

E, também, do STJ:

"3. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018)." (AgRg no AREsp 1770014/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020)".

Além disso, os relatos são confirmados pelas demais testemunhas e informantes, os quais, em síntese, afirmam já terem comprado drogas do acusado Talison. Nesse sentido, observe-se os depoimentos de Lucas Antunes Domingues, Lucas Willian Benatto e Ademir, todos os quais implicaram o acusado Talison na prática da traficância.

Diante deste cenário, é possível concluir de maneira segura que no dia 28 de julho de 2021, o acusado Talison vendeu 50g (cinquenta gramas) de maconha a Lucas Antunes Domingues (fato 02 da denúncia); que, no dia 12 de agosto de 2021, o acusado Talison tinha em depósito 01 (uma) porção de maconha, pesando aproximadamente 14g (catorze gramas) (fato 03 da denúncia); e, ainda, que o acusado Talison tinha, em sua casa, uma um revólver, marca Taurus, Calibre 38, número 683608, acompanhada de 8 (oito) munições, aptos a realização de disparos, conforme Laudo Pericial na arma de fogo e munições (fls. 210-218).

5.2. Em contrapartida, a respeito da imputação de associação para o tráfico (art. 35, da Lei 11.343/06 - fato 01 da denúncia) entendo que o delito não restou demonstrado.

5.2.1. A uma, porque a suposta associação entre os acusados Talison e Bruna não restou suficientemente demonstrada.

No ponto, observe-se que, embora os ambos os acusados tenham confessado a prática de traficância, de maneira individual, negaram que, em qualquer momento tivessem se associado para a prática do delito. Especificamente, a acusada Bruna, em seu interrogatório, confirmou que já vendeu drogas ao acusado Talison, porém disse que

praticava seus atos de traficância sozinha e, em seu conhecimento, Talison era somente usuário de drogas. O acusado Talison apresentou versão similar, tendo dito que é usuário de drogas, mas também as vende. Disse que já adquiriu drogas com a acusada Bruna, mas negou que tenha se associado a ela para tal finalidade. Ademais, as mensagens de textos entre os acusados e demais documentos, anexados às fls. 87-118, conquanto comprovem a compra e venda de entorpecentes entre os acusados (Bruna vendendo para Talison), não demonstram que os acusados tenham se associado para o cometimento do tráfico de drogas.

Ao fim e ao cabo, diante do contexto probatório apresentado, é possível concluir, para além de dúvida razoável, que a acusada Bruna vendia entorpecentes ao acusado Talison. No entanto, não está demonstrado que os acusados tenham se associado para tal finalidade. Isto porque, pelas provas dos autos, infere-se, ao máximo, que Bruna vendia substância ilícitas para Talison, acreditando que este seria usuário de drogas, e, posteriormente, o acusado Talison revendia os entorpecentes, porém sem o conhecimento da acusada Bruna.

Neste sentido, inviável a tipificação – ou, a bem da verdade, a comprovação da materialidade – em relação ao delito previsto no art. 35, da Lei de Drogas (fato 01 da denúncia).

5.2.2. Ainda, a duas, indevida, também, a condenação pela prática do art. 35, da Lei de Drogas, porque não demonstrados os requisitos de 'estabilidade e permanência' necessários à comprovação do delito de associação para o tráfico. A norma penal prevista no art. 35, da Lei 11.343/06, expõe como típica a conduta de "Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei". Conquanto o texto normativo determine como típica a conduta, independente de reiteração, a jurisprudência tem entendimento consolidado no sentido que a 'estabilidade e permanência' são imprescindíveis. Por todos, veja-se: "1. Para a caracterização do crime de associação para o tráfico é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei 11.343/2006. Doutrina. Precedentes." (RHC 108.003/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019).

No ponto, a jurisprudência – de maneira acertada – destaca, ainda, que os requisitos de 'estabilidade e permanência', exigidos para a configuração do delito do art. 35, da Lei 11.343/06, são distintos do elemento de 'reiteração' – este sim dispensado.

"1.5. A estabilidade e permanência, que são elementares do crime de associação para o tráfico, não se confundem com a habitualidade ou reiteração criminosa. 1.6. Inexiste bis in idem em razão do não reconhecimento do crime continuado, pela habitualidade criminosa, e ainda, a condenação pelo delito de associação para o tráfico." (REsp 1501855/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 30/05/2017).

Nesse sentido, o que se verifica é que para a configuração do crime previsto no art. 35, da Lei de Drogas, faz-se necessário demonstrar que a associação para o tráfico preenche os requisitos de 'estabilidade e permanência' – requisitos que, note-se, também são exigidos para a configuração do crime do art. 288, do CP (associação criminosa) –, prescindindo, no entanto, da comprovação de reiteração. Em outras palavras: a conduta do art. 35, da Lei 11.343/06, é típica, ainda que cometida uma única vez (ausência de reiteração), desde que demonstrada a 'estabilidade e permanência'.

No ponto, destaque-se que a exigência de estabilidade e permanência não ofende ao princípio da legalidade. Ao contrário, somente afirma uma diferença normativa e ontológica entre os art. 29, do CP (concurso de pessoas) e o tipo do art. 35, da Lei 11.343/06 (ou, para tais fins, também do art. 288, do CP). Afinal, há uma distinção essencial – reconhecida pelo legislador, sendo, portanto, também normativa – entre o cometimento de um delito juntamente com outro agente (art. 29, do CP – concurso de pessoas) e a associação para o cometimento de delitos (art. 35,

da Lei 11.343/06 e art. 288, do CP). Esta distinção é, justamente, a 'estabilidade e permanência'.

In casu, não restou demonstrado que os acusados tenham se associado, com estabilidade e permanência, para praticar as condutas previstas no art. 35, da Lei de Drogas, dado que ao longo da instrução não se apresentou qualquer prova nesse sentido.

Pelo exposto, seja em razão da ausência de comprovação de estabilidade e permanência, sejam pela não efetiva comprovação da traficância, é imperioso o reconhecimento da atipicidade em relação a imputação do art. 35, da Lei 11.343/06. Dessa maneira, entendo que - a exceção do fato 01 da denúncia - estão comprovadas autorias e materialidades das condutas descritas na exordial, conforme acima exposto.

6. Por esta razão, passa às análises dos tipos penais.

6.1. Como se sabe, para a caracterização do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, não se faz necessário que o acusado seja surpreendido no próprio ato da mercancia ilícita. Isto porque o tipo penal exposto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, é um crime de núcleo misto e alternativo, para o qual basta a configuração de uma das condutas nucleares do tipo para que esteja comprovada a prática penal.

Nesse sentido, observe-se a redação do art. 33, da Lei 11.343/06: "Art.33: Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor a venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar". (grifo nosso).

In casu, em relação ao fato 02 da denúncia, a conduta do agente se ajusta aos verbos descritos no caput do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, haja vista que as provas dos autos demonstram, de maneira segura, que o acusado Talison vendeu, forneceu e negociou 50g (cinquenta gramas) de maconha a Lucas Antunes Domingues. Quanto à aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, entendo ser cabível, dado que o acusado é primário (fls. 46-48) - nunca tendo respondido a outra ação penal -, não ficou comprovado que se dedique a atividades criminosas e nem que integre organização criminosa, o que autoriza a aplicação da cláusula de 'tráfico privilegiado'.

No ponto, destaque-se, especificamente, que acusado possui ocupação lícita e não existem indícios suficientes de que se dedique de maneira 'profissional', permanente e reiterada ao tráfico, antes existindo indícios de que o acusado revendia 'excedentes' da droga que comprova para consumo próprio - situação a qual, por evidente, não descaracteriza o tráfico, descrito no fato 02 da denúncia, mas, certamente, implica em diferenças, em relação aqueles que fazem do comércio ilegal de entorpecentes seu 'meio de vida'.

Diante deste contexto, entendo que devida a aplicação do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, ao fato 02 da denúncia.

6.2. Em relação ao fato 03 da denúncia, entendo que devida a desclassificação para o art. 28, da Lei 11.343/06.

Embora o delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, apresente um tipo plurinuclear alternativo, faz-se necessária a comprovação do dolo na prática da traficância - isto é, a demonstração de que o agir nuclear do tipo se orienta pela finalidade do cometido do ato de tráfico de drogas.

Não sem razão.

Tratando-se delito que expõe diversas ações como típicas, faz-se imprescindível que o cometido da conduta esteja orientado pela finalidade do delito - eis, aqui, um exemplo sintomático da adoção da teoria finalística -, sob pena de tipicidade do art. 33, da Lei 11.343/06, dissolva-se para demais espécies penais, violando, assim, a legalidade penal. Por exemplo, a conduta de 'trazer consigo' ou 'transportar' são espécies nucleares do tipo do art. 33, da Lei de Drogas, porém são também hipóteses que, por vezes, inerentes ao uso de drogas (art. 28). Daí a imperiosa necessidade de demonstrar que a comprovação da conduta típica está orientada pela finalidade de traficância.

No caso em análise, entendo que, a despeito da comprovação do fato de que o acusado Talison tinha 14g (catorze gramas) de maconha em sua residência, há razoável dúvida de seu dolo de traficância em relação aos referidos entorpecentes.

Isto porque, ao longo da instrução restou devidamente comprovado que o acusado Talison comprava drogas de Bruna, com a intenção de utilizá-las e, por vezes, 'revendia' seus 'excedentes' a outras pessoas – situação que, como dito, não lhe exime da responsabilidade pela traficância, em relação ao fato 02 da denúncia. Isto é, o acusado Talison desempenha ora o 'papel' de usuário (comprando de Bruna e consumindo drogas), ora de traficante (revendendo a outras pessoas). Tal situação está fartamente comprovada nos autos, dado que em todos os depoimentos Talison foi descrito como usuário de maconha.

Daí porque, especificamente, em relação as drogas apreendidas em sua residência (14g de maconha), há razoável dúvida a respeito de seu intento de efetiva traficância. É que, embora esteja comprovado que o acusado Talison, por vezes, vendesse entorpecentes, está, igualmente, demonstrada sua condição de usuário. Ou seja, não é possível afirmar, para além de dúvida razoável, que o acusado Talison pretendia vender aquela porção de 14g de maconha apreendida em sua residência (fato 03 da denúncia), sendo igualmente válida a conclusão de que o acusado pretendia utilizar da referida porção.

Neste contexto, não se olvide que a condenação criminal exige não somente a comprovação de um fato criminoso, antes reclamando que esteja comprovado 'aquele' fato criminoso especificamente descrito na denúncia.

No caso em análise, esta cautela é essencial. Isto porque está comprovada, para além de dúvida razoável, a traficância em relação ao fato 02 de denúncia (venda de maconha a Lucas Domingues). No entanto, em situação diversa, em relação a porção de maconha apreendida na casa do acusado Talison, não está devidamente demonstrada a pretensão de traficância, inexistindo, neste outro contexto (fato 03), elementos que conduzam ao inexorável afastamento da hipótese de que o acusado pretendia utilizar o referido entorpecente.

Nesse sentido, entendo que devida a desclassificação da conduta do art. 33, caput, da Lei de Drogas, para o art. 28, deste mesmo diploma legal, especificamente em relação ao fato 03 da denúncia.

6.2.1. No ponto, ressalvo meu entendimento pessoal, no sentido que a tipificação estabelecida no art. 28, da Lei 11.343/06, padece de inconstitucionalidade, na medida em que, em decorrência do princípio da lesividade/ofensividade penal – o qual decorre diretamente do direito de liberdade, previsto no art. 5º, caput, e X, da CF –, é incompatível com a ordem constitucional a criminalização de condutas que não atinjam bens jurídicos de terceiros.

É que, conforme bem expos John Stuart Mill, em seu célebre ensaio Sobre a Liberdade: “só o dano para os interesses de outros – ou a probabilidade elevada de haver dano – pode justificar a interferência da sociedade” (MILL, John Stuart. Sobre a Liberdade. Tradução de Pedro Madeira. Rio de Janeiro: Almedina/Saraiva, 2011, p. 86).

“Nenhuma pessoa devia ser punida simplesmente por estar bêbada; mas um soldado ou um polícia devia ser punido por estar bêbado em serviço. Resumindo: sempre que há um dano claro, ou um risco claro de dano, quer para um indivíduo quer para o público, o caso é retirado do campo da liberdade e colocado no da moralidade ou da lei.

Mas em relação ao dano meramente contingente ou, como pode ser chamado, estrutural, que uma pessoa causa à sociedade através de conduta que nem viola qualquer dever específico para com o público, nem dá azo a danos perceptíveis para qualquer indivíduo definido senão ela mesma, a sociedade pode dar-se ao luxo de suportar essa inconveniência, tendo em vista o bem maior da liberdade humana. Se fosse para punir adultos por não tomarem bem conta de si, preferia que fosse para seu próprio bem, e não com o falso pretexto de os impedir de diminuir a sua capacidade de prestar à sociedade benefícios que esta não finge ter o direito de exigir. Mas não posso aceitar discutir o assunto como se a sociedade não tivesse quaisquer outros meios de elevar os seus membros mais fracos ao padrão normal da conduta racional, a não ser esperar que fizessem algo irracional, e depois puni-los, legal ou

moralmente, por isso.” (MILL, John Stuart. Sobre a Liberdade. Tradução de Pedro Madeira. Rio de Janeiro: Almeidina/Saraiva, 2011, p. 77).

A posição não é distinta na doutrina jurídica.

Conforme exposto, pelo Prof. Salo de Carvalho, em sua tese de mestrado, A Política Criminal de Drogas no Brasil:

“O princípio da lesividade ou da ofensividade complementa, de forma organizativa, o princípio da intervenção mínima. O princípio dispõe que somente poderá ser aplicada penalidade no momento em que a ação infrinja bem jurídico determinado, produzindo-lhe dano - resultado material. Quatro funções específicas são delineadas pelo princípio da lesividade, segundo Nilo Batista: a. proibição de incriminações de atitudes internas; b. proibição de criminalizar condutas que não excedam o âmbito do próprio autor; c. proibição de incriminações de simples estados ou condições existenciais; e, d. proibição de criminalização de condutas desviadas que não afetem qualquer bem jurídico específico. [...].

Sobre a incriminação de atos que não excedam o próprio autor, o princípio se refere à proibição de incriminação de autolesões, crimes impossíveis e atos preparatórios. Relativo ao caso das drogas, toma-se questão fundamental a análise do bem jurídico tutelado e a potencialidade da lesão, principalmente nas condutas usuais.”

(CARVALHO, Salo. A Política de Drogas no Brasil, dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Direito da UFSC, 1996, p. 108-109 - negrito original, grifos próprios).

Também nesse sentido:

“A despeito da importância dada por alguns autores funcionalistas ao conceito de bem jurídico para a afirmação da subsidiariedade e da fragmentariedade do Direito Penal, a existência e tutela penal do bem jurídico somente tem importância se esse conceito for considerado em conjunto com a ofensividade mínima que se exige para a caracterização da tipicidade material do delito (ZAFFARONI, et all., 2010, p. 212). [...].

Em face do princípio da lesividade ao bem jurídico, para E. Raúl Zaffaroni, são ilegítimas incriminações penais que imponham uma determinada moral ou que tenham conteúdo simbólico (ZAFFARONI, et all., 2010, p. 221). Postula também a ilegitimidade do uso da legislação penal a situações em que, embora absolutamente ineficaz para os resultados a que se destina, talvez até mesmo agravando-os, o legislador utiliza-a para tranquilizar a opinião pública e de este modo, proveer al clientelismo político (ZAFFARONI, et all, 2002, p. 489).

Nesse sentido, é de reconhecer-se como função da ofensividade a limitação ao Poder Legislativo, uma vez que devem ser consideradas inconstitucionais as intervenções penais que criminalizam condutas que não ofendem ou sequer geram perigo concreto de lesão a bens jurídicos.

Esses limites impostos ao legislador quando da incriminação de condutas foram sistematizados por Nilo Batista, ao afirmar que o princípio da lesividade tem as seguintes funções: a) proibir a incriminação de uma atitude interna; b) proibir a incriminação de uma conduta que não exceda o âmbito do próprio autor; c) proibir a incriminação de simples estados ou condições existenciais; e d) proibir a incriminação de condutas desviadas que não afetam qualquer bem jurídico, tendo-se por desviada a conduta fortemente desaprovada pela coletividade (BATISTA, 1999, p. 92 e ss).

De fato, não se pode deixar de constatar a inconstitucionalidade de intervenções estatais desse jaez, na medida em que a Constituição consagra o direito à liberdade de opinião e de expressão (art. 5º, IV, VI), a inviolabilidade da intimidade e da vida privada (art. 5º, X) e o pluralismo político e social (art. 3º, IV).

Assim, manifesta-se a inconstitucionalidade de intervenções estatais com tais conteúdos na medida em que reduzem direitos fundamentais, sem que qualquer finalidade social possa ser antevista nessas intervenções. As intervenções estatais são inconstitucionais se não tiverem por finalidade assegurar os objetivos da República Federativa do Brasil expressos no art. 3º da CR/88. Pelo contrário, o que se vislumbra em incriminações sem ofensa a bens jurídicos é que elas não apenas

distanciam a sociedade brasileira de uma sociedade livre (art. 3º, I, CR/88) como ainda ampliam a marginalização, que é objetivo estatal eliminar (art. 3º, III, CR/88). Não se pode perder de vista que: O mais importante compromisso vinculador da atuação do Estado brasileiro decorrente da natureza de nossa Constituição (pacto social) é o reconhecimento da existência de um núcleo inviolável de direitos, constituído pelos direitos fundamentais, cuja tutela é prioridade máxima do Estado e que não podem ser suprimidos nem mesmo a pretexto de atender à vontade da ampla maioria ou ao consenso existente na sociedade. (BRODT, 2005, p. 33).” (ÂREDE, Sirlene Nunes. O Princípio da Ofensividade e a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, in: Revista CEJ, Brasília, Ano XV, n. 55, p. 36-45, out./dez. 2011, p. 37-38).

Além disso, não se pode olvidar que tramita, perante o Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário (RE 635659), com questão de repercussão geral reconhecida, em que se discute a constitucionalidade da previsão normativa do art. 28, da Lei 11.343/06.

É certo que o caso ainda está pendente de julgamento definitivo. Porém, é igualmente inequívoco que os Ministros Gilmar Mendes (relator), Luís Roberto Barroso e Edson Fachin já proferiram votos no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade.

Neste contexto, transcreve-se trecho paradigmático do voto do Ministro Relator: “Nossa Constituição consagra a dignidade da pessoa humana e o direito à privacidade, à intimidade, à honra e à imagem. Deles pode-se extrair o direito ao livre desenvolvimento da personalidade e à autodeterminação.

A proteção do indivíduo contra interferências que se estimem indevidas por parte do Estado pode ser atalhada, dessa forma, com a invocação do princípio da liberdade geral, que não tolera restrições à autonomia da vontade que não sejam necessárias para alguma finalidade de raiz constitucional, e mesmo pelo apelo ao princípio da proteção da dignidade da pessoa humana, que pressupõe o reconhecimento de uma margem de autonomia do indivíduo, tão larga quanto possível, no quadro dos diversos valores constitucionais.

É sabido que as drogas causam prejuízos físicos e sociais ao seu consumidor. Ainda assim, dar tratamento criminal ao uso de drogas é medida que ofende, de forma desproporcional, o direito à vida privada e à autodeterminação.

O uso privado de drogas é conduta que coloca em risco a pessoa do usuário. Ainda que o usuário adquira as drogas mediante contato com o traficante, não se pode imputar a ele os malefícios coletivos decorrentes da atividade ilícita.

Esses efeitos estão muito afastados da conduta em si do usuário. A ligação é excessivamente remota para atribuir a ela efeitos criminais. Logo, esse resultado está fora do âmbito de imputação penal. A relevância criminal da posse para consumo pessoal dependeria, assim, da validade da incriminação da autolesão. E a autolesão é criminalmente irrelevante. São ilustrativos, nesse sentido, os exemplos citados por DANIEL PRADO (Boletim, IBCRIM, outubro/2012, p. 8-9), verbis: [...].

A criminalização da posse de drogas para uso pessoal conduz à ofensa à privacidade e à intimidade do usuário. Está-se a desrespeitar a decisão da pessoa de colocar em risco a própria saúde.

Não chego ao ponto de afirmar que exista um direito a se entorpecer irrestritamente. É perfeitamente válida a imposição de condições e restrições ao uso de determinadas substâncias, não havendo que se falar, portanto, nesse caso, em direito subjetivo irrestrito. Cabe registrar que, com esse mesmo entendimento, a Corte Constitucional alemã negou, em 1994, no julgamento do caso Cannabis, a existência de semelhante direito (Recht zum Rausch), afirmando, com isso, a viabilidade da criminalização do tráfico de cannabis sativa (BverfGE 90,145, 9.3.1994).

Também explicitou que o art. 2, I, da Lei Fundamental alemã, assegura o direito ao livre desenvolvimento da personalidade, mas que o uso de drogas, em especial graças à forte repercussão social que tem, não pode estar nele incluído. Não haveria, assim, um direito a “ficar intoxicado” (“Recht auf Rausch”) assegurado pela Lei Fundamental.

O Tribunal considerou, todavia, que casos envolvendo posse, compra ou importação de pequenas quantidades de maconha para uso eventual devem ser desconsiderados pela insignificância de culpa e da proporção do dano causado.

De forma resumida, o §31 da lei alemã sobre narcóticos (“Betäubungsmittelgesetz”) estabelece que a posse de pequenas quantias de drogas pode não ser criminalizada, exceto em caso de interesse público, e autoriza os promotores a encerrar o caso sem consultar o Judiciário.

Ainda que se afirme que a posse de drogas para uso pessoal não integra, em sua plenitude, o direito ao livre desenvolvimento da personalidade, isso não legitima que se lance mão do direito penal para o controle do consumo de drogas, em prejuízo de tantas outras medidas de natureza não penal, como, por exemplo, a proibição de consumo em lugares públicos, a limitação de quantidade compatível com o uso pessoal, a proibição administrativa de certas drogas sob pena de sanções administrativas, entre outras providências não tão drásticas e de questionáveis efeitos como as sanções de natureza penal.

Na Espanha, por exemplo, entre as sanções administrativas previstas na legislação, há multas de até 30 mil euros e/ou a suspensão da carteira de motorista. São medidas, como se percebe, bem mais eficazes na contenção do consumo do que a simples aplicação de medidas penais sem resultados práticos demonstráveis.

Dessa forma, a prevenção do uso indevido de drogas, um dos princípios do sistema nacional de políticas públicas sobre drogas – art. 4º da Lei 11.343/06 – é uma finalidade estatal válida e pode ser alcançada, com maior eficácia, por meio de um vasto leque de medidas administrativas.

Nesse contexto, a criminalização do porte de drogas para uso pessoal afigura-se excessivamente agressiva à privacidade e à intimidade.

Além disso, o dependente de drogas e, eventualmente, até mesmo o usuário não dependente estão em situação de fragilidade, e devem ser destinatários de políticas de atenção à saúde e de reinserção social, como prevê nossa legislação – arts. 18 e seguintes da Lei 11.343/06. Dar tratamento criminal a esse tipo de conduta, além de andar na contramão dos próprios objetivos das políticas públicas sobre o tema, rotula perigosamente o usuário, dificultando sua inserção social.

A situação ainda é mais grave pela prevalência do consumo de drogas entre os jovens, pessoas em fase de desenvolvimento da personalidade e definição de vida e, por isso, especialmente sensíveis à rotulação decorrente do enquadramento criminal. Da mesma forma, a percepção geral é de que o tratamento criminal aos usuários de drogas alcança, em geral, pessoas em situação de fragilidade econômica, com mais dificuldade em superar as consequências de um processo penal e reorganizar suas vidas depois de qualificados como criminosos por condutas que não vão além de mera lesão pessoal.

Assim, tenho que a criminalização da posse de drogas para uso pessoal é inconstitucional, por atingir, em grau máximo e desnecessariamente, o direito ao livre desenvolvimento da personalidade, em suas várias manifestações, de forma, portanto, claramente desproporcional.” (Voto do Ministro Relator Gilmar Mendes, no RE 635659 – grifos próprios).

Não distinto foi o posicionamento externado pelo Ministro Luís Roberto Barroso:

“VI. FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA A DESCRIMINALIZAÇÃO

Do ponto de vista jurídico, há pelo menos três fundamentos que justificam e legitimam a descriminalização à luz da Constituição:

1. Violação ao direito de privacidade

A intimidade e a vida privada, que compõem o conteúdo do direito de privacidade, são direitos fundamentais protegidos pelo art. 5º, X da Constituição. O direito de privacidade identifica um espaço na vida das pessoas que deve ser imune a interferências externas, seja de outros indivíduos, seja do Estado. O que uma pessoa faz na sua intimidade, da sua religião aos seus hábitos pessoais, como regra devem ficar na sua esfera de decisão e discricionariedade. Sobretudo, quando não afetar a esfera jurídica de um terceiro.

Ex. É preciso não confundir moral com direito. Há coisas que a sociedade pode achar ruins, mas que nem por isso são ilícitas. Se um indivíduo, na solidão das suas

noites, bebe até cair desmaiado na cama, isso não parece bom, mas não é ilícito. Se ele fumar meia carteira de cigarros entre o jantar e a hora de ir dormir, tampouco parece bom, mas não é ilícito. Pois digo eu: o mesmo vale se, em lugar de beber ou consumir cigarros, ele fumar um baseado. É ruim, mas não é papel do Estado se imiscuir nessa área.

2. Violação à autonomia individual

A liberdade é um valor essencial nas sociedades democráticas. Não sendo, todavia, absoluta, ela pode ser restringida pela lei. Porém, a liberdade possui um núcleo essencial e intangível, que é a autonomia individual. Emanação da dignidade humana, a autonomia assegura ao indivíduo a sua autodeterminação, o direito de fazer as suas escolhas existenciais de acordo com as suas próprias concepções do bem e do bom. Cada um é feliz à sua maneira. A autonomia é a parte da liberdade que não pode ser suprimida pelo Estado ou pela sociedade.

Exs mais óbvios: o Estado e a sociedade não podem decidir com quem você vai se casar, qual deve ser a sua religião ou que profissão você vai seguir.

As pessoas têm, igualmente, o direito de escolher os seus prazeres legítimos. Há quem faça alpinismo, voe de ultraleve, participe de corridas de automóvel, ande de motocicleta ou